

1500632-60.2021.8.26.0019

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: ANDRE CARLOS DE OLIVEIRA

Comarca: Americana

Foro: Foro de Americana

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 25/03/2022

... de atos de mercancia para a configuração do tráfico.

Confira-se: "Para que haja tráfico, não é mister seja o infrator colhido no próprio ato de venda da mercadoria proibida. O próprio art. 37 da Lei Antitóxicos (atual 28, § 2º, da Lei nº 11.343/06, 'contrário sensu'), dá as coordenadas da caracterização do tráfico ao estipular que essa classificação se fará em ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Americana

Foro de Americana

1ª Vara Criminal

Avenida Brasil Sul, 2669, Americana-SP - cep 13468-390

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

1500632-60.2021.8.26.0019 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500632-60.2021.8.26.0019

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Inquérito Policial (Flagrante), Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2062976/2021 - 03º D.P. AMERICANA, 16594978 - 03º D.P. AMERICANA, 378/21/346 - 03º D.P. AMERICANA, 2062976/2021 - DISE- DEL.SEC.AMERICANA, 378/21/346 - DISE- DEL.SEC.AMERICANA, 2062976 - DISE- DEL.SEC.AMERICANA

AMERICANA, 378/21/346 - 03º D.P. AMERICANA, 2062976/2021 - DISE- DEL.SEC.AMERICANA, 378/21/346 - DISE- DEL.SEC.AMERICANA, 2062976 - DISE- DEL.SEC.AMERICANA

AMERICANA, 378/21/346 - 03º D.P. AMERICANA, 2062976/2021 - DISE- DEL.SEC.AMERICANA, 378/21/346 - DISE- DEL.SEC.AMERICANA, 2062976 - DISE- DEL.SEC.AMERICANA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

GABRIEL JACOB DE OLIVEIRA

Tramitação prioritária

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). ANDRE CARLOS DE OLIVEIRA

VISTOS.

GABRIEL JACOB DE OLIVEIRA está sendo processado como incurso nas sanções do artigo 33, "caput" da Lei 11.343/06, acusado de no dia 04 de março de 2021, por volta de 11h20, na Rua Santa Inês, 345, Santa Sofia, nesta cidade, trazer com ele e ter em depósito, para fins de comercialização, 07 tabletes da droga maconha (Cannabis sativa L - tetraidrocanabinol), pesando cerca de 59,3 gramas. Na casa, os policiais apreenderam um invólucro de maconha, com peso de 10 gramas, além de cinco sacos plásticos, do tipo ziplock, substâncias que provocam dependência física e psíquica, assim o fazendo sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

A denúncia foi instruída com Inquérito Policial.

Aplicou-se o rito da Lei 11.343/2006. Manifestaram-se defesa e acusação. A denúncia foi recebida em 25 de novembro de 2021 (fls. 145/146). Na instrução foram inquiridas duas testemunhas comuns. Ao final, o réu foi interrogado.

Sem mais requerimentos, substituídos os debates por memoriais, a acusação requereu a procedência da denúncia, com a condenação do réu, provada a ocorrência do crime, materialidade e autoria. Discorre sobre pena e regime (fls. 179/183).

A Defesa arguiu em preliminar ausência de justa causa. Não concorreu para a prática do crime. Não causou lesão ao bem juridicamente protegido. No mérito, a absolvição por insuficiência probatória. O acusado não tinha a intenção de vender drogas, tampouco foi encontrado em atividade de traficância. Não havia denúncias a seu respeito ou variedade de entorpecentes. Alternativamente, desclassificação para o crime do artigo 28 da Lei de Drogas. O réu era viciado, portava a quantia de 59,3g (cinquenta e nove gramas e três decigramas) de Cannabis Sativa para seu próprio consumo, compartilhado com uma amiga. Invoca o 'in dubio pro reo'. O acusado possuía residência fixa e ocupação lícita.

Não se dedicava à vida de traficância e nem integrava organização criminosa. Em caso de condenação, pretende redução da pena pela menoridade e primariedade (artigo 33, par. 4º), no limite máximo, ou seja, 2/3 (dois terços), devido a pequena quantidade de cannabis sativa. Faria jus à substituição da privativa de liberdade por restritivas de direitos, com regime brando e recurso em liberdade (fls. 187/195).

É o relatório.

DECIDO.

A preliminar de inépcia da denúncia não procede.

A denúncia descreveu com suficiência o fato delituoso, com todas as circunstâncias, permitindo ao réu desenvolver com amplitude o direito de defesa.

No ponto, ensina Guilherme de Souza Nucci:

Concisão da denúncia ou da queixa: é medida que se impõe, para não tornar a peça inicial do processo penal em uma autêntica alegação final, avaliando provas e sugerindo jurisprudência a ser aplicada. Diferentemente da área cível, no processo criminal, a denúncia ou queixa deve primar pela concisão, limitando-se a apontar os fatos cometidos pelo autor (denunciado ou querelado), sem juízo de valoração ou apontamentos doutrinários e jurisprudenciais. A peça deve indicar o que o agente fez, para que ele possa se defender. Se envolver argumentos outros, tornará impossível o seu entendimento pelo réu, prejudicando a ampla defesa. Ensina Espínola Filho que “a peça inicial deve ser sucinta, limitando-se a apontar as circunstâncias que são necessárias à configuração do delito, com a referência apenas a fatos acessórios, que possam influir nessa caracterização. E não é na denúncia, nem na queixa, que se devem fazer as demonstrações da responsabilidade do réu, o que deve se reservar para a apreciação final da prova, quando se concretiza (ou não) o pedido de condenação” (Código de Processo Penal Brasileiro anotado, v. 1, p. 418). No mesmo sentido: Rogério Lauria Tucci (Habeas corpus, ação e processo penal, p. 188).” (Código de Processo Penal Comentado, 2019, pág. 199).

Na jurisprudência:

“Apesar de o art. 41 do Código de Processo Penal aludir à exposição de todas as circunstâncias do fato criminoso, não há necessidade de minúcias, devendo o denunciante ou querelante primar pela concisão, limitando-se a apontar os fatos cometidos pelo(s) réu(s) para não tornar a peça inicial do processo uma verdadeira alegação final” (TJMG, Ap. Crim. 1.0210.07.046790-2/0001(1) – MG, 5.^a.C. C., rel. Adilson Lamounier, 24.11.2009, v.u.).

A singela leitura da peça acusatória revela ter descrito os fatos e todas as suas circunstâncias, capitulando adequadamente o comportamento do agente ao tipo penal infringido, independente da solução de mérito. Proporcionou ao réu o exercício da ampla defesa e pleno conhecimento sobre a acusação.

No mérito, a ação penal é procedente.

Na fase administrativa, alegou que saiu de casa com a sua motocicleta com destino até a casa de uma amiga, que preferia não identificar. Ela pediu para que arrumasse

maconha para fumarem juntos. Pagou R\$ 150,00 pela droga. Em seguida, foi até o condomínio onde a moça morava, no Bairro Belvedere. No momento em que parava a motocicleta para entrar no condomínio, foi abordado pela polícia militar e revistado. Os policiais localizaram em seu bolso sete buchas de maconha. Após, autorizou que entrassem em sua casa, onde foi encontrado mais uma bucha de maconha, que havia adquirido anteriormente. Os plásticos vieram com a maconha comprada, retirou e os colocou dentro do mesmo saco plástico. Foi a primeira vez que adquiriu a droga, nunca praticou ato semelhante (fls. 14).

Em juízo, alegou que em nenhum momento falou que iria vender drogas para pessoa do sexo feminino. Na verdade, disse para os policiais que iria levar as drogas para a moça que morava no prédio, iriam consumir os entorpecentes juntos. Ela estava no local, mas os policiais não quiseram saber da mulher, nada perguntaram a seu respeito. Ela ficou com medo e entrou no prédio. Foi colocado na viatura e os policiais foram até a sua casa, onde morava com a sua avó. Permaneceu dentro do carro. Encontraram uma bucha perdida por lá, era pouca coisa. A moça tinha chegado na cidade há pouco tempo, começaram a conversar e ela disse que gostava da droga. Pegou os entorpecentes e foi até a casa dela, interfonou no apartamento e estacionou a moto enquanto ela descia, momento em que os policiais chegaram e o abordaram. Não tentou ligar a moto para deixar o local. Sabia onde a mulher morava, mas não tiveram mais contato, já faz há um ano. Nem sabia se ela ainda morava no mesmo local. Foi preso por um dia. Após ser solto, não procurou mais a mulher porque os pais dela não sabiam que ela usava entorpecentes.

A negativa do réu não convence.

O policial militar, Danilo Machado Garcia, lembrou-se de que a equipe estava em patrulhamento no bairro Belvedere, realizavam a 'Operação Saturação'. Ao acessarem a Rua Santa Inês, logo na esquina, avistou Gabriel montado em uma moto, estacionada perto de um condomínio. Ao perceber a presença da viatura, o suspeito desviou o olhar e tentou ligar a moto, o que despertou a desconfiança da equipe e ensejou a abordagem. Na revista, localizou com o acusado, próximo das vestes íntimas, uma porção de entorpecentes, contendo sete tabletes pequenos de maconha. Indagado, informalmente, o acusado disse iria entregar as drogas para uma moça, sem fornecer maiores informações. Como tem se tornado muito comum a realização de entrega de drogas nas casas, na modalidade Delivery, questionaram se havia mais entorpecentes na residência. Gabriel respondeu que sim, mas que era pouca quantidade. Ele autorizou a entrada da equipe no imóvel, juntamente com a sua avó. Durante as buscas realizadas, encontrou no quarto, dentro do guarda-roupas, mais uma porção pequena de maconha, além de cinco pacotinhos de saquinhos zip, para o acondicionamento da mesma droga. Diante dos fatos, ele foi conduzido até a Central de Polícia Judiciária. Já tinha visto Gabriel pelo Bairro São Manoel e Cariobinha, mas nunca o abordou anteriormente. Não havia denúncias a seu respeito. Gabriel nada mencionou sobre ser usuários de drogas, alegou que iria entregar os entorpecentes para uma mulher. Não se recordava da versão do acusado perante a autoridade policial.

O colega de farda, Isaac Hebert Moreira de Matos, reafirmou a versão, ratificando-a em uníssono. Destacou que patrulhavam pelo bairro Belvedere. Ao acessarem a Rua Santa Inês, avistaram o réu sentado em uma motocicleta.

Ao notar a presença da equipe, o suspeito demonstrou nervosismo e fez menção de deixar o local rapidamente. O acusado foi abordado e revistado. Com Gabriel, encontraram algumas porções de maconha. Ao ser questionado, alegou que era o proprietário da droga e que estava naquele local para entregá-las para uma moça desconhecida, sem maiores detalhes. Indagado se possuía mais entorpecentes em sua residência, Gabriel respondeu que tinha mais uma porção e franqueou a entrada da equipe no local, juntamente com a sua avó. Durante as buscas no imóvel, localizaram outra porção da mesma substância. Diante dos fatos, o réu foi conduzido até a Central de Polícia Judiciária. Gabriel não alegou que as drogas eram para o seu uso, ele disse que saiu do bairro dele para levar os entorpecentes para vender, iria repassar para uma moça desconhecida. Era o motorista da viatura, quem entrou no imóvel foi o encarregado, Machado. Na casa onde Gabriel morava, também se fazia presente a avó dele. Não conhecia o réu, não havia denúncia a seu respeito. Ele não

ofertou qualquer resistência, apenas fez menção de deixar o local antes da abordagem.

Bem certa, a prova, assim, quanto a efetiva ocorrência do tráfico, na medida em que o réu trazia com ele drogas, as quais não em quantidade expressivas e nem de nocividade mais preocupante (maconha), era destinada a terceiro, que não ousou em momento algum revelar.

Na casa também mantinha outro tanto da mesma droga.

As diligências, bem resumidas pelos policiais militares, nos depoimentos judiciais, garantido o contraditório amplo, descreveram que durante operação e patrulhamento, suspeitaram do nervosismo do acusado ao avistar a viatura. Abordaram-no, ele já levava com ele um tanto de drogas, sete tabletes de maconha e confessou que entregaria para uma mulher. Acrescentou que na casa teria outro tanto da droga, que foi efetivamente apreendida.

Na casa, além da maconha, foram encontrados petrechos, cinco sacos plásticos do tipo 'zip', que se destinam ao embalo do entorpecente.

A droga apreendida, sintomaticamente, estava acondicionada no mesmo tipo de plástico, individualmente, revelando propícias para a entrega imediata.

A alegação de que a droga seria para uso próprio ou em comum com a mulher não foi provada e muito menos é crível, pela citada forma em que estavam embaladas, além da quantidade de saquinhos próprios para seu o acondicionamento.

Como ensina Adalberto José Q. T. de Camargo Aranha, "O entendimento jurisprudencial é no sentido de que o álibi constitui um a exceção de defesa e, como tal, cabe ao incriminado o ônus de sua demonstração" (Da prova no processo Penal, editora Saraiva, 7ª ed. 2006, p.18).

O STF já teve oportunidade de decidir nesse sentido, no HC 68.964-7-SP, rel. Min. Celso de Mello, DJU 22.04.1994, cuja ementa tem o seguinte teor:

"O álibi, enquanto elemento de defesa, deve ser comprovado, no processo penal condenatório, pelo réu a quem seu reconhecimento aproveita".

Também:

"Quem invoca um álibi, para ser absolvido, carece de cumpridamente demonstrá-lo, não bastando, para tal fim, produção de elementos de convicção que não excluam de vez a possibilidade de ter sido o autor da infração" (TJSP, AP. 53.726, Rel. Azevedo Franceschini).

Em suma, a prova não autoriza qualquer hesitação quanto ao convencimento da responsabilidade criminal do réu, para o fim de traficar.

Trata-se de crime de ação múltipla e conteúdo variado, não carecendo a prática de atos de mercancia para a configuração do tráfico.

Confira-se: "Para que haja tráfico, não é mister seja o infrator colhido no próprio ato de venda da mercadoria proibida. O próprio art. 37 da Lei Antitóxicos (atual 28, § 2º, da Lei nº 11.343/06, 'contrário sensu'), dá as coordenadas da caracterização do tráfico ao estipular que essa classificação se fará em consonância com a natureza e a quantidade da substância apreendida, o local e as condições em que se desenvolveu a ação criminosa, as circunstâncias da prisão, bem como a conduta e os antecedentes do agente" (RT 584/347).

"ENTORPECENTE - Tráfico - Agente que não comercializou a droga - Caracterização pela simples guarda, pois o tipo do art. 12 da Lei 6.368/76 é de conteúdo variado ou misto alternativo" (TJRS, RT 745/633).

E, por pertinente: "ENTORPECENTE - Tráfico - Caracterização - Crime de perigo abstrato - Desnecessidade da prática de efetivo ato de comércio, bastando que o agente seja apanhado trazendo consigo, guardando ou mantendo em depósito a substância entorpecente, para finalidade de venda. Inteligência do art. 12, caput, da Lei 6.368/76" (TJSP, RT 793/576).

A versão de Policial Militar, do mesmo modo, é segura e não deve ser desprezada tão só pela condição de agente da autoridade.

No TJSP:

"Ressalta-se, por oportuno, que os guardas civis municipais não estão impedidos de depor e seus depoimentos devem ser valorados como quaisquer outros, até porque as testemunhas prestaram depoimentos coesos, sob o crivo do contraditório, e, portanto, gozam de idoneidade, especialmente porque não se demonstrou que tivessem

interesse concreto de incriminar indevidamente o réu, de modo que seus depoimentos constituem meio de prova idôneo para embasar a condenação" Apelação Criminal nº 3029152-31.2013.8.26.0602, da Comarca de Sorocaba, sessão permanente e virtual da 9ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, j. 25 de fevereiro de 2022. FÁTIMA GOMES

E no C. STF

"HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. NULIDADE DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. INSUFICIÊNCIA DAS PROVAS DE ACUSAÇÃO. DEPOIMENTOS PRESTADOS EM JUÍZO POR AUTORIDADES POLICIAIS. VALIDADE. REVOLVIMENTO DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. É da jurisprudência desta Suprema Corte a absoluta validade, enquanto instrumento de prova, do depoimento em juízo (assegurado o contraditório, portanto) de autoridade policial que presidiu o inquérito policial ou que presenciou o momento do flagrante. Isto porque a simples condição de ser o depoente autoridade policial não se traduz na sua automática suspeição ou na absoluta imprestabilidade de suas informações." (STF HC 87.662-5/PE Rel. Min. Carlos Ayres Britto j. 05.09.06 DJU 16.02.07);

"O valor de depoimento testemunhal de servidores policiais - especialmente quando prestado em Juízo, sob a garantia do contraditório - reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. O depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se demonstrar - tal como ocorre com as demais testemunhas - que as suas declarações não encontram suporte nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos." (STF-HC 73.518-5 - Rel. Min. Celso de Mello - DJU 18.10.96, p. 39.846);

Finalmente, no C. STJ:

"Conforme entendimento desta Corte, o depoimento de policiais responsáveis pela prisão em flagrante do acusado constitui meio de prova idôneo a embasar o édito condenatório, mormente quando corroborado em Juízo, no âmbito do devido processo legal. Precedentes.3. Habeas corpus não conhecido." (HC 236.105/SC, Rel. Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 05/06/2014, DJe 12/06/2014). Indiferente a alegação do réu, assim, de que não teria envolvimento com o tráfico, na conduta de vender o entorpecente, na medida em que a acusação é certa de imputar a ele a conduta de trazer com ele e manter em depósito, para esse fim, que poderia por evidente (a venda) ser realizada por terceira pessoa, que não identificou. Também o fato de ser usuário de drogas não afasta a traficância, quando o porte de eventual droga é absorvido pelo crime de maior severidade, no caso, o tráfico. A alegação de necessidade, em sua versão, de todo o modo não lhe dá direito ou permissão para trazer com ele e ter em depósito drogas, para o grave crime de tráfico.

A prova, resumidamente, é boa e suficiente, com prisão em flagrante delito, certeza visual do delito, apreensão da droga e depoimentos de policiais.

Por evidente, o princípio da insignificância não se aplica ao crime de tráfico de drogas, crime de perigo abstrato e em que é irrelevante a quantidade da substância apreendida (neste sentido, 5ª T. STJ, Rel. Min. Jorge Mussi, REsp 1.637.113), o que de toda a forma é incompatível com a expressividade de drogas apreendidas.

A materialidade da infração foi provada pelo auto de exibição e apreensão (fls. 05/06), pelo laudo de constatação (fls. 08/10) e pelo exame químico toxicológico (fls. 90/92).

Por isso de rigor a condenação.

Fixação das penas.

O réu é primário. A quantidade de drogas era normal para o tipo de infração, tráfico. Fixo a pena base no mínimo legal.

Na segunda fase, incide a atenuante da menoridade. Impossível redução da pena, nesta segunda fase, aquém do mínimo. Mantenho inalterada a pena base.

Na terceira fase, pela primariedade e não comprovação de que integrasse associação ou organização criminosa, possível a redução de pena no percentual de dois terços,

o que se faz em atenção à quantidade-nocividade de droga apreendida (10 gramas e 59,3 de massa líquida da substância 'maconha' TETRAHIDROCANNABINOL (THC)). Possível a substituição da privativa de liberdade por restritivas de direitos, reconhecido o tráfico privilegiado e a somatória final da pena, com estipulação do regime aberto para o caso de revogação.

Ressalvado entendimento pessoal a respeito da gravidade da conduta, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao julgar o HC nº 111.840/ES, afastou a obrigatoriedade do regime inicial fechado para os condenados por crimes hediondos e equiparados, devendo-se observar, para a fixação do regime inicial de cumprimento da pena, o disposto no artigo 33, c.c. o artigo 59, ambos do Código Penal.

Depois, o Superior Tribunal de Justiça estabeleceu o entendimento de que: "Esta Corte, na esteira do posicionamento do Supremo Tribunal Federal, entende ser possível nas condenações por tráfico de drogas, em tese, a fixação de regime menos gravoso, bem como a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, sempre tendo em conta as particularidades do caso concreto." HC nº 239.999/MS, 5ª Turma, Rel. Min. Laurita Vaz, DJe 21.08.2014.

Na mesma evolução, com a promulgação da Lei nº 13.964/2019 (popularmente conhecida como "pacote anticrime"), houve necessidade de maior reflexão pelos julgadores. Dentre as alterações previstas no regime legal, houve alteração expressa da Lei de Execuções Penais, em especial no tocante ao "tráfico privilegiado": Lei de Execuções Penais: Art. 112. A pena privativa de liberdade será executada em forma progressiva com a transferência para regime menos rigoroso, a ser determinada pelo juiz, quando o preso tiver cumprido ao menos: (Redação dada pela Lei nº 13.964, de 2019). (...) § 5º Não se considera hediondo ou equiparado, para os fins deste artigo, o crime de tráfico de drogas previsto no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343, de 23 de agosto de 2006.

Assim, o regime inicial aberto, analisada a detida conduta dos autos, é de ser imposto ao condenado, primário.

Isto posto, JULGO PROCEDENTE a ação penal que a JUSTIÇA PÚBLICA promoveu, para condenar GABRIEL JACOB DE OLIVEIRA às penas de um (01) ano e oito (08) meses de reclusão, regime inicial aberto e cento e sessenta e seis (166) dias-multa, piso, por infração ao artigo 33, 'caput' e § 4º, ambos da Lei 11.343/2006.

Presentes os pressupostos legais, substituo a pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, consistente em prestação de serviços à comunidade, pelo período da pena e mais dez (10) dias-multa, piso, fixado o regime aberto para a hipótese de descumprimento.

Não há valor mínimo indenizatório a ser arbitrado.

Vinculado o numerário apreendido com o crime cometido, decreto a sua perda em favor da União, bem como os objetos apreendidos, ficando autorizado, quanto a estes últimos, doação ou destruição, acaso inservíveis ou sem valor econômico, o que será certificado.

Certifique-se quanto à destruição da droga.

Isento o réu de custas, assistido que está por defensor nomeado e presumida a necessidade (fls. 40).

Após o trânsito em julgado, inscreva-se o nome do réu no rol dos culpados.

Faculto recurso em liberdade, porque assim o réu respondeu aos atos do processo. P.I.C.

Americana, 24 de março de 2022.

ANDRÉ CARLOS DE OLIVEIRA
JUIZ DE DIREITO

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA